

1500117-60.2021.8.26.0557

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ANDERSON VALENTE

Comarca: Guaíra

Foro: Foro de Guaíra

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 25/02/2022

... CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. APLICAÇÃO DA LEI N. 8.072/90 AO TRÁFICO DE ENTORPECENTES PRIVILEGIADO: INVIABILIDADE. HEDIONDEZ NÃO CARACTERIZADA. ORDEM CONCEDIDA.

1. O tráfico de entorpecentes privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.313/2006) não se harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes definido no ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guaíra

Foro de Guaíra

1ª Vara

Av. 17, 414, Guaíra - SP - cep 14790-000

1500117-60.2021.8.26.0557 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500117-60.2021.8.26.0557

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

João Pedro de Paiva Paes

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDERSON VALENTE

Vistos.

I. JOÃO PEDRO DE PAIVA PAES, qualificado a fls. 15, foi denunciado e viu-se processado como incurso no artigo 33, caput c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343, de 23.08.2006, porque no dia 12 de fevereiro de 2021, por volta das

15h29min, na Avenida 23 altura do nº 1.548, Bairro Nossa Senhora Aparecida, nesta cidade e Comarca de Guaíra, teria guardado, para finalidade de entrega ao consumo de terceiros, vinte e quatro porções de cocaína, com peso bruto aproximado de 8,28g, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Narra a denúncia que “após receberem informação anônima de que o acusado estaria traficando e as ocultava em cima de uma árvore, policiais militares dirigiram-se até o referido endereço e, em patrulhamento, avistaram JOÃO PEDRO mexendo em um buraco localizado em cima de uma árvore, instante em que o acusado tentou se evadir do local mas caiu ao solo. Ao efetuarem buscas na árvore, localizaram, 24 eppendorfs contendo substância com características análogas à cocaína, pesando o total de 8,28 gramas. Com JOÃO PEDRO foram localizados a quantia de R\$ 115,00 reais em quatro notas de R\$ 20,00, três notas de R\$ 10,00 e uma nota de R\$ 5,00, bem como um aparelho celular”, sendo que “Nas imediações do local há uma praça no qual tem construída uma quadra de esportes”.

Denúncia de fls. 145/146 recebida em 11 de março de 2021 (fls. 147/148). Devidamente citado (fls. 201), o Acusado apresentou defesa preliminar (fls. 203/208), rejeitada por não configurar o caso de absolvição sumária (fls. 209/211). Durante a instrução foi colhida prova oral e interrogado o Réu (fls. 237/244).

Em alegações finais o ilustre representante do Ministério Público pugnou pela condenação do Réu, nos exatos termos da denúncia (fls. 235/236).

A douta Defesa, por sua vez, ressaltou que o Réu deveria ser absolvido por falta de provas (fls. 245/248).

Eis o relatório.

II. Fundamento e DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade delitiva ficou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 01/04), boletim de ocorrência de fls. 05/06, auto de exibição e apreensão de fls. 07/08, pelo laudo de constatação provisória de substância entorpecente (fls. 10/12), comprovante de depósito de fls. 135, no laudo de exame químico toxicológico (fls. 184/186) e pela prova oral colhida durante a persecução penal.

A autoria é certa contra o Réu que, na fase inquisitorial optou pelo silêncio (fls. 04), ao passo que em Juízo negou o teor da denúncia, sustentando, a fls. 242/244, que é usuário de drogas e foi ao local adquirir entorpecente, sendo que ao chegar ali as pessoas correram, somente ele sendo abordado, de forma que os policiais acreditaram que a droga era dele, não sabendo exatamente de quem seria porque havia várias pessoas ali, um ponto de venda de entorpecentes. Ademais, o dinheiro que carregava era fruto de seu trabalho e é usuário de cocaína.

De início deve ser destacado que, como se sabe, o direito ao silêncio é cláusula constitucionalmente assegurada, mas não é crível se acreditar que aquele que tenha sido injustamente preso pela prática de um crime assemelhado ao hediondo tivesse a frieza de manter-se calado para somente em Juízo informar a prisão equivocada, demonstrando que o Réu nada tinha a indicar em sua defesa no momento de sua prisão, cabendo salientar brilhante excerto de acórdão do E. Tribunal de Justiça Bandeirante, pois ele “assumiu comprometedor, ainda que legalmente tolerada, postura silente, quando é certo que aquele que se vê injustamente acusado, trata, logo, de anunciar a injustiça da acusação, se convidado a falar sobre ela” (TJSP, Ap. 990.09.059887-5, 3ª C.D.Crim., Rel. Des. Geraldo Wohlers, j. 04.08.2009).

Sua versão não se sustenta.

O policial militar Marcelo disse, em fls. 237/239, que foram informados que o Réu estaria traficando drogas na Vila Aparecida, para lá se dirigindo, ocasião em que o avistaram, em uma bicicleta, mexendo em cima de uma árvore na praça, justamente o local que mencionava a delação, instante em que o Acusado, ao perceber a presença militar, fugiu, mas foi alcançado na rua debaixo, retornando àquele lugar, encontrando os vinte e quatro pinos de cocaína e, com o Réu, dinheiro. Ao ser indagado, o Acusado disse que estava guardando a droga para um amigo, mas não declinou seu nome e é conhecido dos meios policiais pelo tráfico. Na mesma linha o depoimento do policial Rogério, encartado em fls. 240/241.

Nem se olvide pelo fato de a acusação se embasar somente no depoimento prestado por policiais, que é válido e está em consonância com as demais provas, sem existência de qualquer indicativo de sua imprestabilidade, motivo por que não podem ser descartados, notadamente porque o Réu não ofertou qualquer resistência válida ao depoimento deles, nem mesmo os contraditando.

A condição funcional não os torna suspeitos, valendo, outrossim, o princípio de presunção de legitimidade dos atos administrativos praticados. Nesse diapasão, "Com relação aos depoimentos de policiais, os entendimentos jurisprudenciais têm convergido na direção de que são eles válidos e aptos ao suporte de uma condenação, pois aqueles agentes da autoridade prestam os seus esclarecimentos sob o compromisso da verdade como qualquer testemunha e as suas narrativas devem ser entendidas como verdadeiras até a produção de provas em contrário, com demonstração da falácia, recaindo o ônus da produção destas na esfera da defesa, situação que ocorreu nos autos.

Pequenas divergências encontradas no cotejo dos depoimentos prestados pelos policiais, sem atingirem o âmago da questão, devem ser desprezadas, posto que podem ser produto do posicionamento dos mesmos quando da diligência efetuada e das tarefas de cada um deles naquele momento, além do entrelaçamento de situações diante do elevado número de ocorrências que tais policiais atendem no dia a dia, sem o comprometimento daquilo que narraram" (TJSP, Ap. 990.08.168537-0, 10ª C.D.Crim., Rel. Des. Otávio Henrique, j. 16.04.2009).

A conduta do Acusado indica, pois, que no dia, horário e local apontados na denúncia, guardava em uma praça considerável quantidade de substância entorpecente para fins de traficância. A isso se chega com a prova coligida aos autos, notadamente a quantidade de cocaína apreendida, em porções individuais prontas para comercialização, bem como a forma como estava o narcótico escondido em uma árvore, além do fato de que ele, ao avistar os policiais militares, empreendeu fuga, assim como por ser conhecido dos meios pela prática do narcotráfico, ali um notório ponto de venda de drogas.

Tais condutas apontam que o Réu iria utilizar o entorpecente apreendido para fins de mercantilização, consoante se extrai do artigo 28, parágrafo 2º, da Lei 11.343, de 23.08.2006.

Dessa forma, considerando o quadro posto, descabe se falar em insuficiência probatória. Oportuno salientar que "Nunca é demais lembrar, de outro lado, que é desnecessária a prova de ato de comércio, bastando que o agente traga consigo ou mantenha em depósito a droga para essa destinação, ainda que futura, na medida em que a consumação não exige resultado" (TJSP, Ap. 990.09172372-0, 5ª C.D.Crim., Rel. Des. Pinheiro Franco, j. 03.12.2009).

De outro modo, é forçoso se reconhecer que o Acusado traficava em uma praça. Assim, perfeitamente caracterizada a causa de aumento de pena tipificada no artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/06.

Diante desse quadro probatório, não há como se deixar de reconhecer que no dia,

horário e local indicados na denúncia o Acusado foi surpreendido, quando guardava, para fins de comercialização, a substância entorpecente descrita na inicial.

Inexistem causas que afastem a ilicitude da conduta, excluam a culpabilidade do agente ou extingam a punibilidade, razão pela qual reconheço a ocorrência do delito e passo à dosimetria da pena.

O Réu não ostenta antecedentes criminais certificados nos autos que possam ser considerados para exasperação da pena-base (cf. fls. 233/234), agindo com dolo normal do delito, com o que fixo sua pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no menor valor, à míngua da comprovação de suas condições financeiras.

Na segunda fase da dosimetria, muito embora o Réu fosse menor de vinte e um anos de idade à época da consumação do crime a pena, mantida em seu piso, não pode ser diminuída aquém de seu patamar mínimo na segunda fase da dosimetria, uma vez ser mera circunstância atenuante (artigo 65, inciso I, do Código Penal). Esta orientação levou o C. Superior Tribunal de Justiça, inclusive, a editar a Súmula nº 231: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

À derradeira, em vista da incidência da causa de aumento de pena do artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas, majoro sua pena em 1/6, à míngua de critérios que indicassem possibilidade de se aumentar a pena acima da fração mínima, e a fixo em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em seu piso legal.

Não havendo qualquer demonstração nos autos de que se dedique à atividade criminosa organizada, malgrado praticasse o narcotráfico, faz jus à causa de diminuição da pena prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas. No caso dos autos, dadas as circunstâncias particulares, não havendo qualquer demonstração clara de tratar-se de pessoa envolvida com a criminalidade organizada, reduzo a pena no patamar máximo de 2/3 (dois terços), totalizando 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, no seu piso, que torno definitiva ante a inexistência de demais causas legais modificadoras.

Neste ponto, é de se reconhecer que o Pleno do Supremo Tribunal Federal decidiu que o tráfico privilegiado não tem natureza de crime equipado ao hediondo, verbis: "HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. APLICAÇÃO DA LEI N. 8.072/90 AO TRÁFICO DE ENTORPECENTES PRIVILEGIADO: INVIABILIDADE. HEDIONDEZ NÃO CARACTERIZADA. ORDEM CONCEDIDA.

1. O tráfico de entorpecentes privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.313/2006) não se harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes definido no caput e § 1º do art. 33 da Lei de Tóxicos.
2. O tratamento penal dirigido ao delito cometido sob o manto do privilégio apresenta contornos mais benignos, menos gravosos, notadamente porque são relevados o envolvimento ocasional do agente com o delito, a não reincidência, a ausência de maus antecedentes e a inexistência de vínculo com organização criminosa.
3. Há evidente constrangimento ilegal ao se estipular ao tráfico de entorpecentes privilegiado os rigores da Lei n. 8.072/90.
4. Ordem concedida" (HC118.533/MS, Relª Minª Carmen Lúcia, j. 23.06.2016).

Desta forma, tomando por base a ausência de hediondez do tráfico privilegiado, assim como sua primariedade e menoridade relativa, sua pena deverá ser cumprida desde o início em regime aberto, o que é aqui consignado por determinação legal (artigo 59, inciso III, do Código Penal) e em face de eventual e futura revogação das penas restritivas de direitos sobre as quais se falará a seguir. Presentes os requisitos previstos no artigo 44 e no seu parágrafo 2º, segunda parte, do Código

Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, consistentes em prestação pecuniária de 1 (um) salário mínimo em favor de entidade assistencial (artigo 43, inciso I, do Código Penal) e prestação de serviço à comunidade ou entidade pública (artigo 43, inciso IV, do Código Penal), pelo prazo da condenação, que devem ter seu cumprimento fixado pelo Juízo das Execuções Criminais.

Lado outro, deixo de fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando o artigo 387, inciso IV, do CPP, porquanto o crime apurado é classificado como vago, assim entendido aquele que tem por sujeito passivo a sociedade, destacando, outrossim, que não se comprovou qualquer dano causado em sujeitos passivos secundários (pessoa submetida aos riscos da lesão).

À derradeira, tendo em vista que o Acusado foi condenado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, sendo com ele localizada quantia em dinheiro vinculada ao crime, evidenciando-se ser o numerário fruto da venda de drogas ilícitas, com fulcro no artigo 63, caput, do aludido diploma legal, decreto a perda do celular e dos valores apreendidos com o Réu, que deverão ser encaminhados em favor da União, com o trânsito em julgado desta sentença (artigo 63, parágrafo 1º).

III. Isto posto e tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado e, em consequência CONDENO o Réu JOÃO PEDRO DE PAIVA PAES, qualificado nos autos, à pena de 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, ao valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, com correção monetária a partir do fato delituoso, como incurso no artigo 33, caput c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06, em regime aberto, sendo que a pena de reclusão é substituída, por igual prazo, por pagamento de 1 (um) salário mínimo à entidade assistencial desta Comarca e à prestação de serviço à comunidade ou à entidade pública, a ser fixada pelo Juízo das Execuções Criminais. No mais, decreto o perdimento do telefone celular e do valor apreendido com ele, este depositado em fls. 135 em favor da União.

Após o trânsito em julgado, lancem seus nomes no Rol dos Culpados (artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal) e encaminhe-se o dinheiro apreendido em fls. 135 e o telefone celular em favor da União.

Tendo em vista o regime inicial de cumprimento de pena e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, não se mostra necessária a decretação de sua prisão cautelar, podendo aguardar o julgamento do recurso em liberdade, nos termos do artigo 387, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

São devidas custas na forma da lei.

P.R.I.C.

Guaíra, 25 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA